

1001831-70.2022.8.26.0010

Classe: Tutela Antecipada Antecedente

Assunto: Indenização do Prejuízo

Magistrado: Carlos Antonio da Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... volta das 23:15 horas, foi vítima de roubo praticado na Rua Frei Caneca, quando saía do Shopping Center, conforme boletim de ocorrência em anexo; que os assaltantes levaram seu aparelho celular; que a autora bloqueou a linha telefônica e o IMEI, porém, na manhã do dia seguinte constatou que todo o valor disponível, a título de cheque especial de sua conta corrente, foi transferido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional X - Ipiranga

3ª Vara Cível

Rua Agostinho Gomes, 1455, São Paulo - SP - cep 04206-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001831-70.2022.8.26.0010 - lauda

SENTENÇA

C O N C L U S ã O

Processo Digital nº:

1001831-70.2022.8.26.0010

Classe - Assunto

Tutela Antecipada Antecedente - Indenização do Prejuízo

Requerente:

Daniela Franklin Cianciulli

Requerido:

Banco Itaú Unibanco S.a. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Antonio da Costa

Feito nº 1001831-70.2022.

Vistos.

DANIELA FRANKLIN CIANCIULLI promoveu ação contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A alegando que é a autora correntista do requerido Itaú; que no dia 16/02/2022, por volta das 23:15 horas, foi vítima de roubo praticado na Rua Frei Caneca, quando saía do Shopping Center, conforme boletim de ocorrência em anexo; que os assaltantes levaram seu aparelho celular; que a autora bloqueou a linha telefônica e o IMEI, porém, na manhã do dia seguinte constatou que todo o valor disponível, a título de cheque especial de sua conta corrente, foi transferido para sua conta do Picpay e, após, para contas de terceiros; que foram realizados um pix de R\$ 1.985,55 e um pix de R\$ 4.200,00 do Itaú para o Picpay, totalizando R\$ 6.188,55; que a conta bancária não tinha movimentações constantes e o valor transferido foi exatamente o valor que a suplicante possuía disponível a título de cheque especial; que os estelionatários também tentaram fraudar o sistema de segurança do Nubank, mas houve o envio de e-mail de segurança à autora, e os fraudadores não conseguiram burlar o sistema de segurança do Nubank; que o Picpay

enviou e-mail para a autora sobre "código de alteração de senha", mas não foi capaz de impedir o ato ilícito, a exemplo do réu Itaú; que as entidades-rés devem responder solidariamente pelos danos causados à autora; que a responsabilidade civil da parte ré é objetiva; e que também sofreu abalo psíquico e emocional, fazendo jus à indenização por dano moral. Requereu a concessão de tutela provisória visando compelir o suplicado Itaú a abster-se de cobrar o valor do saque fraudulento e dos respectivos encargos, e de negativar o nome da autora, e a procedência da ação para declarar inexigível o "débito" atrelado à fraude e condenar a parte ré ao pagamento da indenização por danos morais de R\$ 12.500,00. Atribuiu à causa o valor de R\$ 18.000,00 (fls. 01/15). Juntou documentos (fls 16/50).

A decisão de fls. 51/52 concedeu em parte a tutela provisória.

A decisão de fls. 67 determinou o revigoramento da tutela provisória.

A requerida Picpay apresentou contestação aduzindo que é uma instituição de pagamento, consistindo em um aplicativo de pagamentos que funciona como uma "carteira digital"; que não possui legitimidade para figurar no polo passivo porque não praticou qualquer ação comissiva ou omissiva; que a totalidade do valor desviado adveio do banco Itaú; que os pagamentos questionados pela autora foram confirmados por biometria; que não houve falha nos procedimentos de segurança da contestante; que a comunicação tardia da consumidora é fato relevante para a consecução dos alegados prejuízos; que não se justifica a inversão do ônus da prova; que não incorreu em falha na prestação de serviços; que a comunicação tardia configura culpa exclusiva da autora; que o ato praticado por terceiro configura fortuito externo; que não está promovendo qualquer cobrança contra a autora; que não houve dano moral, mas sim mero aborrecimento; e que eventual indenização deve ser arbitrada com moderação (fls. 71/100). Juntou documentos (fls. 101/154).

O banco-réu contestou a ação acenando com ilegitimidade passiva porque não houve falha na prestação dos serviços; que as transações questionadas foram com a correta utilização do dispositivo itoken e senha eletrônica; que o sistema do contestante possui diversas barreiras de segurança; que o PIX é uma transferência eletrônica de valores "on line" em tempo real que permite o pagamento de bens e serviços, de qualquer valor, a qualquer hora do dia, todos os dias do ano (dia útil ou não), podendo ser utilizada entre pessoas físicas e jurídicas e sem custo; que o pagamento e o recebimento ocorrem em uma plataforma única operada pelo Banco Central responsável por armazenar os dados dos usuários e efetivar a transação; que houve culpa exclusiva da autora que não cumpriu o dever contratual de guarda da senha, afastando a responsabilidade objetiva do réu; que houve fortuito externo; que não houve fortuito interno; que é inaplicável a tese de perfil transacional; que não há defeito no serviço do réu a atrair a responsabilidade objetiva; que não houve danos material e nem moral; que eventual indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação; e que não se justifica a inversão do ônus da prova (fls. 159/184). Juntou documentos (fls. 185/198 e 202/216).

A autora manifestou-se em réplica (fls. 217/222 e 230/238) e juntou documento (fls. 239/240).

Concedeu-se a oportunidade para especificação de provas (fls. 252), manifestando-se somente a parte ré (fls. 255 e 256 e 257).

Vieram-me conclusos. Decido.

A autora pretende sujeitar a parte ré à tutela jurisdicional deduzida, donde emerge a pertinência subjetiva passiva, pelo que rejeito a preliminar suscitada pelos contestantes e passo a examinar o mérito.

Consta do boletim de ocorrência nº 0000366967/2022 (fls. 19/21) elaborado em 17/03/2022 pela autora que (no dia 16/03/2022): "FUI ABORDADA POR UM CASAL A MÃO ARMADA NO MEIO DA RUA E PEDIRAM O MEU CELULAR DESBLOQUEADO".

O boletim de ocorrência, conforme é cediço, goza da presunção "juris tantum" de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. Além disso não há como compelir a autora a provar um fato negativo, isto é, que não realizou as transações (de R\$ 1.985,55 e R\$ 4.200,00) bancárias contestadas.

Destarte e diante da verossimilhança da versão da parte autora, segundo a qual as transações bancárias questionadas foram efetuadas por fraudador(es) após a

subtração do seu telefone celular, incumbia ao banco-réu comprovar que tais transações seriam compatíveis com o perfil de utilização da autora, porém, o suplicado não juntou qualquer extrato de movimentação (de conta corrente) objetivando demonstrar que em alguma outra oportunidade ou ocasião a autora teria efetuado alguma transação ou pagamento utilizando exclusivamente o valor (total ou parcial) que a autora possuía disponível a título de cheque especial, ou seja, o requerido não comprovou que as operações bancárias seriam compatíveis com o perfil transacional da autora (CPC, art. 373, inciso II), razão pela qual é forçoso reconhecer que houve falha no sistema de detecção e prevenção de (eventuais) fraudes do banco-réu mormente porque ele, repita-se, não comprovou que as operações eram compatíveis com o perfil (transacional) da parte autora.

Assim, é forçoso concluir que houve falha na prestação de serviço prestado pelo banco réu porque não conseguiu evitar as operações fraudadas a despeito delas discreparem do perfil transacional habitual da suplicante.

Insta ressaltar que a responsabilidade do banco réu por falha no serviço é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 20 da Lei 8.078/90, além do que, considerando a relevância do serviço prestado, responde pelo risco de sua atividade, conforme artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Alguns consideram a hipótese como 'caso fortuito interno', pois inerente à atividade econômica desenvolvida pelo banco. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ ("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"), pelo que outro não poderá ser o desfecho da presente ação senão reconhecer a inexigibilidade do débito (e respectivos encargos) atrelado(s) às transações fraudulentas (de R\$ 1.985,55 e R\$ 4.200,00) ora questionadas, não se justificando a condenação (solidária) da requerida PicPay porque não se vislumbra qualquer falha atribuível à segunda suplicada.

E no sentido de que a instituição bancária deve ser responsabilizada pelos indevidos saques realizados na conta de seus clientes, confira-se a seguinte ementa de um acórdão do E. TJSP:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - SAQUES INDEVIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PELO RISCO DA ATIVIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVE A MÁ-FÉ DO CLIENTE, QUE NÃO SE PODE PRESUMIR - FRAUDE - FATO COMUM - SISTEMA BANCÁRIO FALHO - RECURSO IMPROVIDO." (Apelação nº 9293971-24.2008.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos Eduardo Prata, j. 12/09/2008).

E nem se acene com mero aborrecimento ou dissabor, pois o autor necessitou contratar advogado e ingressar em juízo para obstar a cobrança do limite de cheque especial - LIS (fls. 49/50) que foi alvo das transferências fraudulentas, bem como para evitar a iminente negativação de seu nome, restando, pois, configurado o dano moral.

E no que tange ao "quantum" da reparação pelo dano moral saliento que a doutrina inclina-se a adotar uma posição eclética ou mista que atribui ao ressarcimento natureza satisfatória para o ofendido e punitiva para o agente do ato ilícito, ao invés de considerá-lo exclusivamente sanção ao ofensor ou ressarcimento ao ofendido. Segundo Maria Helena Diniz, a prestação pecuniária "viria neutralizar os sentimentos negativos de mágoa, dor, tristeza e angústia, pela superveniência de sanções positivas, de alegria, satisfação, porque possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em certa medida, poderia atenuar seu sofrimento", incumbindo ao Juiz, com base em sua experiência, fixar um valor que não seja nem inexpressivo para o ofendido e nem excessivo para o ofensor, assim, partindo desses pressupostos e sopesando as condições das partes, a gravidade de lesão e sua repercussão e as circunstâncias fáticas, arbitro a indenização por danos morais em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por derradeiro acrescento que segundo a Súmula 326 do STJ "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", logo, a fixação da indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não justifica a imposição de verbas sucumbenciais ao autor.

Ante o exposto:

a) julgo procedente em parte a ação que DANIELA FRANKLIN CIANCIULLI promoveu contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A e, conseqüentemente, declaro a inexigibilidade, em relação à autora, de qualquer cobrança do valor (e encargos) relativo(s) ao limite de cheque especial - LIS (fls. 49/50) que foi alvo das transferências fraudulentas (de R\$ 1.985,55 e R\$ 4.200,00), torno definitiva a tutela provisória (fls. 51/52) e condeno o suplicado ao pagamento da indenização por danos morais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária (tabela do TJSP) a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, ficando resolvido o processo com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC);

b) julgo improcedente a ação que DANIELA FRANKLIN CIANCIULLI promoveu contra PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Condeno o banco suplicado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da Patrona da autora arbitrados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (tabela do TJSP) a partir da publicação e acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês) a partir do trânsito em julgado (desta sentença), nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e § 16 do CPC.

Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios do Patrono da requerida Picpay arbitrados em R\$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente (tabela do TJSP) a partir da publicação e acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês) a partir do trânsito em julgado (desta sentença), nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e § 16 do CPC, mas ressalto que tais verbas sucumbenciais não poderão ser exigidas da autora, beneficiária da Justiça gratuita (item "1" de fls. 51), enquanto perdurar sua hipossuficiência econômica (CPC, art. 98, § 3º).

P. I. C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA